

作协议》约定，抵押物的市场价值应当为案涉抵押物在强制执行程序中，由法院委托重庆某资产评估房地产土地估价有限公司确定的价值，即17866700元。理由为：虽然案涉抵押物最终的成交价格为10005352元，但该价格是在法院的主导下、按照民事执行强制程序的要求形成的一种价值兑现结果，这种交易方式显然有别于正常情形下的市场交易方式。首先，司法拍卖程序的起拍价参照评估价，可在不低于评估价70%的基础上起拍，一拍不成在一拍价格基础上降低20%范围内进行二拍，二拍不成可进入变卖程序，也可进行三拍，整个程序的推进、议价都是按照既定规则进行，且必须在法定期限内完成；同时，对买受人价款的支付方面也有要求，必须在法院限定的时间内全额付清。此外，参加竞拍的主体参拍时还应缴纳一定数额的保证金。司法成交价格更多的是特定主体在特定时间范围内、按照特定竞价方式促成的房屋兑现价，是各方主体根据司法拍卖规则妥协下的合意选择，该价格显然不能体现为市场价值。而在开放的市场交易方式过程中，权利人可根据自身房屋价值设定交易方式和交易规则，价格调整幅度自由进行，不受具体时间、买受人类型等因素的约束，款项支付方式可选择一次性付款、分期付款、抵押贷款等多种类型，充分体现了交易自由。相关机构在评估房屋价格之时，也更多的是通过参考市场交易模式的价格基础确定具体拍卖房屋的市场价值。因此，司法评估机构确定的评估价更接近于市场价。现周某、周某某在上述协议约定的范围内自愿调减为18500000元，属法律允许范围之内，法院予以支持。

重庆市南岸区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十四条、第五百八十五条、第六百八十一条、第六百八十八条、第七百条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉担保制度的解释》第十七条、第十八条、第二十条之规定，判决如下：

一、被告某机电公司于判决生效之日起十日内向原告周某某支付赔偿金18500000元，并支付资金占用损失；

二、被告某机电公司于本判决生效之日起十日内向原告周某某支付律师费50000元；

三、被告甲置业公司等对被告某机电公司的上述债务向原告周某某承担连带清偿责任；

四、驳回原告周某某的其他诉讼请求。

一审宣判后，双方均提起上诉。

重庆市第五中级人民法院作出判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、抵押人追偿时的观点分歧

保证人向债权人承担责任后向债务人行使追偿权时，已由民法典作出了明确规定，追偿范围较易明确和量化。保证人承担保证责任之时，多以金钱代债务人向债权人清偿债务，保证人的代偿金额即为其可追偿的范围，司法实践已经就此形成统一的裁判标准。然而在以特定房产等提供抵押担保的情况下，物业的价值并非恒定不变的，抵押人对其享有的权益也处浮动状态。以房产等不动产提供抵押担保的抵押人代替债务人清偿债务后，向债务人追偿时虽可根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》的规定，参照保证人的追偿方式和路径进行，但因所提供担保的房产等不动产存在订立担保合同之时的债权人预估价格、执行评估价格、执行拍卖价格等，极易在认定物保人追偿范围时产生分歧。尤其是在抵押人与债务人明确约定了追偿金额或追偿损失计算方式的情况下，究竟以何标准和尺度确定追偿范围，既是司法裁决时的争议，更是法官评判时的困惑。一种观点认为，追偿权以填补损失为基础，房产拍卖之时成交的金额就是抵押人的损失，故追偿权的范围和金额就是前述成交金额，无须考虑合同约定的范围或其他参考价值；另一种观点则认为，在有偿担保的情况下，担保已不再是传统民法意义上的增信举措，而是市场交易模式下的商事活动，应当充分尊重合同约定，保护契约精神，在合法合理的价值内应当不拘泥于房屋的成交金额，抵押人可在合同约定的幅度内主张相应金额。

二、在合同基础上运用市场交易思维辨别抵押物价值

本案中，抵押物为商铺，不仅具有其本身的所有权价值，同时还内藏着其

使用权价值即租赁价值，商品属性显著。抵押物既有静态的所有权价值，也有动态的使用权价值。基于上述特征，周某某与某机电公司订立《抵押融资合作协议》时，明确约定了其抵押物被拍卖后的赔偿金额计算方式，即按抵押物市场价值（抵押物权证记载的建筑面积 $\times$ 22000元/平方米）加上抵押物五年租金（抵押物权证记载的建筑面积 $\times$ 100元/平方米/月 $\times$ 60月）之和计算。该约定是两方经过多轮磋商后充分协商的结果，也是理性经济人参加商事活动中做出的判断取舍，其不再局限于传统的民事担保模式，而是体现了更多商事交易活动的风险与收益并存的市场化模式。无论是抵押物自身价值的计算标准，还是抵押物出租单价，都没有偏离合同缔结时即2016年的市场行情，具有充分的市场性、合理性。在抵押物被强制执行后，如果以执行程序中的拍卖成交价为周某某的追偿范围，显然不能兼顾抵押房产的商品属性，且也背离了抵押担保合同关于追偿范围的约定。

抵押物通过人民法院执行程序拍卖后清偿债务人的债务时，其成交价是按照民事执行强制程序的规定形成的一种价值兑现方式。该成交价格是在特定主体在特定时间范围内、按照特定竞价方式促成的房屋兑现价，是各方主体根据司法拍卖规则妥协下的合意选择，未经过开放状态下充分的市场竞争，显然不能等同于市场价值。此时的拍卖价格显然不能实际反映出抵押人对抵押物的真实价值损失。而执行程序中选定的中介机构在评估房屋价格时，则是在市场交易模式的基础上，充分考量市场行情、周边环境、地段、品质等因素后按照既有成熟的计价方式确定的，相对更接近于房屋的市场价值。基于此，在合同约定的损失计算范围内，抵押人主张按照房屋评估价行使追偿权，人民法院应予支持。本案的裁判思路为抵押人行使追偿权提供了参考性指引。

编写人：重庆市南岸区人民法院 王烁 李明刚

民法典实施前抵押优先受偿未获支持，
民法典实施后又诉请确认抵押预登记效力的分析认定
——某银行诉张某某等金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省昌乐县人民法院(2023)鲁0725民初3305号民事裁定书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行

被告：张某某、某担保公司、某房地产公司

【基本案情】

2011年11月3日，某银行与张某某签订借款合同，约定向原告贷款168000元用于购房，借款期限240个月，以昌乐县建设路某室作为抵押，并办理了预抵押登记。某担保公司、某房地产公司承担保证责任。现借款人未按合同约定的还款期限按时偿还借款，构成违约。某房地产公司已经取得不动产权证，并办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形。

原告某银行诉至法院，于2019年7月12日立案，原告诉请对案涉抵押物优先受偿，被告某担保公司、被告某房地产公司承担连带责任保证。后法院于2019年9月10日作出民事调解，认定：被告张某某欠原告某银行借款本金128620.67元及利息(利息自2019年9月6日按照贷款合同约定利率计算至借款实际偿还之日止)，被告张某某自2019年9月6日起按个人住房(商业用

房)借款合同约定履行偿还借款本息义务;若被告张某某未按个人住房(商业用房)借款合同约定履行还款义务,原告某银行有权对全部欠款本息申请执行;被告某房地产公司对被告张某某的借款本息承担连带担保责任,至抵押物他项权利证书办理完成之日止;被告某担保公司对被告张某某的借款本息承担连带担保责任。

2023年7月6日,原告某银行向法院再次提出诉讼,请求确认原告的抵押权自办理预告登记之日设立,原告对案涉抵押物优先受偿;请求判令被告某担保公司、被告某房地产公司承担连带责任保证。

【案件焦点】

民法典实施前原裁判或调解书未支持抵押权优先受偿,新担保制度解释实施后原告诉请抵押预登记效力的认定。

【法院裁判要旨】

山东省昌乐县人民法院经审理认为:原告某银行与被告张某某、某担保公司、某房地产公司金融借款合同纠纷案,法院曾于2019年7月12日立案,于2019年9月10日作出(2019)鲁0725民初2148号民事调解书。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第五项规定:“对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件,当事人又起诉的,告知原告申请再审,但人民法院准许撤诉的裁定除外。”即当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉,同时符合构成重复起诉的条件:后诉与前诉的当事人相同;后诉与前诉的诉讼标的相同;后诉与前诉的诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的,裁定不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉。该案涉调解书已经发生法律效力,当事人又起诉,原告可申请再审,裁定驳回起诉。

山东省昌乐县人民法院裁定如下:

驳回原告某银行的起诉。

【法官后语】

本案所涉及的是民法典实施前，原告请求对抵押物享有优先受偿权，原裁判或调解书未支持抵押权优先受偿，新担保制度解释实施后原告请求抵押预登记效力如何处分的分析认定。《中华人民共和国民法典》施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法有规定的，可以适用《中华人民共和国民法典》的规定，但是明显减损当事人合法权益，增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。民法典实施前暨新担保制度解释实施前，对仅办理抵押预登记的抵押财产一般裁判抵押权人不享有优先受偿权，新法实施后，裁判标准发生变化，“当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿，经审查已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形的，人民法院应予支持”。抵押权人如何维护自己的权益，成为裁判者不能忽略的问题，在审判实践中新担保制度解释实施后原告请求抵押预登记效力如何处分应从以下方面进行标准掌握。

一、不予受理或驳回起诉的情形

1. 银行第一次起诉时要求优先受偿法院判决未支持或者调解中未涉及抵押权的效力认定，银行在民法典实施后，起诉要求确定抵押权效力实现优先受偿权。即当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合构成重复起诉的条件：后诉与前诉的当事人相同；后诉与前诉的诉讼标的相同；后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》从判断标准和例外情形正反两方面对“一事不再理”原则作出了阐述。

2. 银行第一次起诉时要求确定抵押权的优先受偿权，法院判决未支持或者调解中未涉及抵押权的效力认定，银行在民法典实施后，原告通过特殊程序即可对担保物权实现优先受偿权。应正确理解和适用“一事不再理”原则，应遵循主客观统一的构成标准整体把握该两条的立法原意和实质要求。“后诉与前

诉的当事人相同”，不能简单从形式上、文义上理解为当事人数量、地位的完全相同，在适用时应作目的解释，即结合争议诉讼标的，新增的诉讼标的、诉讼请求依附于前诉的诉讼标的、诉讼请求，在生效判决已经驳回前诉诉讼请求，即对前诉所涉优先受偿的诉请不予支持的结果生效的情况下，后诉通过特殊程序实现担保物权纠纷，实质上是否定前诉的裁判结果，因此，本案与前诉的诉讼标的、诉讼请求存在同一性，亦参照一审不再审，不予受理。

二、予以支持的情形

银行第一次起诉时只要求偿还欠款未要求确定抵押权的效力，法院判决未涉及抵押权或者调解中未涉及抵押权，银行在民法典实施后，起诉要求确定抵押权效力或通过特殊程序即实现担保物权纠纷实现优先受偿权。即银行提起的诉涉及新的法律关系，诉讼标的和诉讼请求都不重复，不符合重复起诉的构成要件。当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿，经审查存在尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形，导致不具备办理抵押登记条件的，人民法院不予支持；经审查已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形的，人民法院应予支持，并应当认定抵押权自预告登记之日起设立。

三、诉讼时效的考量

第二次起诉是否考虑诉讼时效问题，主债权诉讼时效期间届满后，抵押权人主张行使抵押权的，人民法院不予支持；抵押人以主债权诉讼时效期间届满为由，主张不承担担保责任的，人民法院应予支持。主债权诉讼时效期间届满前，债权人仅对债务人提起诉讼，经人民法院判决或者调解后未在民事诉讼法规定的申请执行时效期间内对债务人申请强制执行，其向抵押人主张行使抵押权的，人民法院不予支持。

因确定裁判是对特定时点上当事人之间实体法律关系状态的判断，故确定判决仅对基准时之前发生的事项具有既判力，对基准时之后的事项没有既判力。提供阶段担保的开发商，就如同在判决后，部分履行，法律事实发生了变化，

但结合法律溯及力规则，不宜再进行诉求或申请案件再审。如果抵押权人不通过实现担保物权纠纷主张优先受偿权，根据民事诉讼法规定，担保人作为利害关系人提出实现担保物权纠纷，对预抵押的效力认可可以推定开发商阶段性担保的终止，系新的履行情况，可以抗辩连带责任。新担保制度解释实施后在审判实践中如何掌握原告再次提出诉请抵押预登记效力，有利于梳理阶段性担保和预抵押之间“割不断理还乱”的“罗生门”，“举一纲万目张”，利于房地产市场健康有序发展。

编写人：山东省昌乐县人民法院 刘文强 胡希斌

商品房销售合同解除在先，预抵押房产不能优先受偿

——某银行诉缪某某、某地产公司金融借款合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省永泰县人民法院(2023)闽0125民初594号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人

原告：某银行

被告：缪某某、某地产公司

【基本案情】

2015年5月29日，缪某某因购房需要向某银行申请按揭贷款。2015年11月11日，某银行、缪某某、某地产公司共同签订《个人购房担保借款合同》，约定借款280000元，借款期限240个月，借款利率5.65%，还款方式为等额本

金按月还款，若未按时还款应支付罚息、复利、赔偿相应损失；某地产公司提供阶段性连带保证担保至缪某某取得房产权属证书并办妥抵押登记手续止。2015年6月5日，双方就案涉房产办理预售商品房抵押权预告登记。贷款发放后，缪某某自2022年6月起未按时还款。某银行遂于2023年2月2日诉至法院，要求缪某某还本付息、承担银行为实现债权支出的相关费用、对预抵押房产优先受偿、某地产公司承担连带清偿责任。

另查明，案涉房产所在项目已于2016年办理建筑物所有权首次登记。因缪某某未能按时向银行还款，导致某地产公司承担保证责任垫付部分按揭款，故某地产公司于2022年9月2日提起诉讼，法院于2022年11月30日作出判决，解除双方之间的《商品房买卖合同》。

【案件焦点】

1. 某银行能否就预抵押房产优先受偿；2. 某地产公司是否应当承担连带保证责任。

【法院裁判要旨】

福建省永泰县人民法院经审理认为：缪某某与某地产公司签订的《商品房买卖合同》已被判决解除，那么基于该合同设立的将来以缪某某为权利人的不动产物权将不可能实现，以缪某某为义务人的抵押登记也不可能实现，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款“当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿，经审查存在尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形，导致不具备办理抵押登记条件的，人民法院不予支持”的规定，某银行就案涉房产办理抵押登记的条件将不能成就，故其诉请就案涉房产优先受偿的主张无事实和法律依据。根据《个人购房担保借款合同》约定，某地产公司的阶段性

保证责任至“借款人取得房产权属证书，并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续完成之日止”，故某地产公司仍应承担连带保证责任。

福建省永泰县人民法院判决如下：

一、缪某某应于本判决生效之日起十日内偿还某银行借款183166.39元及利息、复利、罚息1436.52元(利息、复利、罚息暂计至2022年7月25日，此后按《个人购房担保借款合同》约定计至借款本息还清之日止)；

二、缪某某应于本判决生效之日起十日内支付某银行律师代理费2346元；

三、某地产公司对以上第一、二项款项承担连带清偿责任，承担连带责任后，有权在其承担保证责任的范围内向缪某某追偿；

四、缪某某、某地产公司应于本判决生效之日起十日内支付某银行财产保全案件申请费1454元、公告费260元；

五、驳回某银行的其他诉讼请求。

宣判后，原、被告均未提出上诉，判决已发生法律效力。

【法官后语】

人民法院在审理金融借款合同纠纷案件中，审查银行能否就预抵押的房产优先受偿时，应依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条(以下简称担保制度司法解释第五十二条)，从“已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形”两个正向条件，以及“尚未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形”三个负向条件，及“导致不具备办理抵押登记条件”这一兜底条款入手，逐一分析审查，以确定银行是否可以优先受偿。

一、当前主流审判思路

担保制度司法解释第五十二条第一款的实施成为法院判决银行能否优先受偿以及开发商是否承担阶段性保证责任的分水岭。此前，遵循最高法的公报案例，法院一致认为抵押预告登记不同于抵押登记，不能直接判定享有抵押物优先受偿权，但可以在判决办理抵押正式登记后优先受偿。该司法解释出台后，就未办理首登的案件，法院一律不支持银行优先受偿。但在已办首登未办产权证的情况下，存在不支持优先受偿，由开发商继续承担阶段性保证责任；支持

优先受偿，阶段性保证责任免除；支持优先受偿并承担阶段性保证责任等三种判决。即便在“已办理首登未办证”情况下，还存在三个方面的分歧：第一，抵押预告登记是否失效；一种认为应当以预抵押房产权利人可办理或知道可办理抵押登记之日起九十日后，另一种认为应是开发商办理首登之日起九十日后。第二，抵押和阶段性保证之间的关系，主流观点认为“是非此即彼关系”；另一种认为没有必然关系，应当依据合同约定。第三，阶段性保证责任的截止时间，大部分认为应是“首登”之日，一些认为应当尊重合同约定，个别认为在抵押登记手续办妥或法院限定的协助办理期限届满后免除。

二、预抵押房产能否优先受偿的重点考量因素

关于预抵押房产优先受偿的法律适用，主要涉及《中华人民共和国民法典》第二百二十一条第二款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第五条、担保制度司法解释第五十二条第一款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条等。在案件类型上主要有四种：（1）开发商请求解除商品房销售合同，银行作为有独立请求权的第三人主张开发商直接返还购房款；（2）开发商请求解除商品房销售合同，同时银行诉请解除贷款担保合同；（3）商品房销售合同和贷款担保合同均继续履行，银行诉请优先受偿、开发商承担阶段性保证责任；（4）商品房销售合同已解除，银行另案诉请购房者返还借款、就预抵押房产优先受偿及开发商承担阶段性保证责任。本案就属于第四种。此类案件中，银行并非诉请解除贷款合同，因而，并不适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条；商品房销售合同已被解除，抵押担保合同却依然有效，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第五条规定，“债权消灭”的事由是预告登记的买卖不动产物权的协议被认定无效、被撤销，或者预告登记的权利人放弃债权，并未包含合同被“解除”，因此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第五条亦不适用。故而，该类案件主要适用《中华人民共和国民法典》第二百二十一条第二款和担保制度司法解释第

五十二条第一款。

（一）预告登记失效

《中华人民共和国民法典》第二百二十一条规定的“预告登记失效”包括债权消灭和自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记。关于债权消灭，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第五条规定了合同被认定无效、被撤销，或权利人放弃债权，但并未包含合同被解除的情形。关于超过时效，主流观点认为，在商品房预售和贷款担保合同关系中，预售预告登记的权利人是购房者，但能否申请所有权登记受制于开发商是否办理了首登；抵押预告登记的权利人是银行，但能否申请抵押登记受制于购房者是否办理产权证。因此，判断是否超过申请期限，应综合考量抵押登记条件是否成就、不能成就的原因是否可归责于银行等因素。

（二）不具备办理抵押登记条件

抵押预告登记的基础债权包含“未来物权的实现”和“未来抵押权的实现”。因此，抵押预告登记不同于预售预告登记，其债权基础包括商品房销售合同和抵押合同。当商品房销售合同和抵押合同均解除时，法院可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定，分别就两个合同解除的法律后果作出相应的审理。但，当商品房销售合同解除但抵押合同继续履行时，在商品房销售合同关系中，开发商和购房者互负责任之后，双方之间的债权消灭；而，贷款担保合同继续履行，银行和借款人（购房者）之间的债权并未消灭，此时，作为预售预告登记权利人的购房者将不可能再成为标的房产的所有权人，自然不能以“他人”（开发商所有）的房产抵押。据此，一旦商品房销售合同被解除，不论贷款担保合同是否继续履行，都应当认为预售预告登记和抵押预告登记都因失去依托的基础而不可实现。该不可实现，并非因债权消灭，而是因不具备办理本登记条件。

（三）开发商与购房者恶意串通

在商品房预售中还存在开发商与买受人恶意串通，以虚假商品房销售合同骗取银行抵押贷款，借款由开发商使用，当借款无法清偿时，开发商以解除商

商品房销售合同为由阻止办理抵押本登记、排除银行优先受偿权。对此，最高法院认为，银行作为善意第三人无违规放贷等行为，已尽审慎注意义务，虽然预售合同被确认无效，但该无效不能对抗基于信赖预告登记效力而为后续交易的善意第三人，因此抵押预告登记未失效。

三、预抵押房产优先受偿的审查思路

（一）明晰法定要素

考量预抵押房产能否优先受偿的核心是将来抵押权有否设立的可能。根据担保制度司法解释第五十二条，要考量三个“反向条件”、一个兜底条款及两个“正向条件”。其中，“反向条件”和兜底条款即首登未办理、预登记财产与首登不一致、抵押预告登记失效、不具备办理登记条件；“正向条件”包含已办理首登、预告登记未失效。在“反向条件”的“抵押预告登记失效”上包含“债权消灭”“超过申请登记时效”两项；“债权消灭”又包含合同无效、被撤销以及权利人放弃三个方面。在“正向条件”的“预告登记未失效”上，需考量“预售预告登记未失效”和“抵押预告登记未失效”两项。因此，法官在判断预抵押房产是否可以优先受偿时，实际需要考虑十项法律明确规定的要素。

（二）专项分析重点要素

审判实务中因审查要素多，且“反向条件”和“正向条件”并非一一对应，因此往往容易忽略重点要素的审查。

1. 预告登记是否有效。在不能优先受偿上，只需审查“抵押预告登记”是否失效，预售预告登记仍可有效。而，可以优先受偿而言，则需同时审查“预售预告登记”和“抵押预告登记”是否都有效，但凡有一项失效，则不能优先受偿。

2. 预告登记与首登不一致。在认定不能优先受偿时，预登记财产与首登财产不一致是“不具备登记条件”的详细情形，直观明了。但，在认定可以优先受偿时，法条并未写明该必要前提，实践中该问题出现的比率也相对较低，因此常被法官忽略。

3. 不具备登记条件。不能优先受偿的要素中，未办理首登、抵押预告登记

失效、登记不一致都是“不具备办理登记条件”情形的列举，法条以“等”字，表明了条文并未逐一列举所有情形，如本案。因此，法官还应重点审查“是否具备办理登记条件”。

（三）排除例外情形

对于开发商与买受人恶意串通骗取银行抵押贷款，再以预售合同解除排除银行优先受偿等例外情形，法官审理时应注重审查开发商与购房者是否恶意串通损害银行利益以及银行是否尽到审慎注意义务。对于这两项的审查，应由银行举证证明开发商与购房者恶意串通及银行已尽审慎注意义务。

编写人：福建省永泰县人民法院 连娜

以未成年人个人财产设定抵押的效力认定规则

——王某某诉付某某等借款合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2024)京03民终1749号民事判决书

2. 案由：借款合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):王某某

被告(被上诉人):付某某、付某、赵某

【基本案情】

赵某与付某系夫妻关系，付某某系二人之子，借款发生时付某某尚未年满16周岁。

2022年9月3日,王某某与付某某、付某、赵某签订《借款合同》《借条》,约定付某某因家庭支出向王某某借款3000000元,借款期限为2个月,借款利率为每月按全部借款金额的1.2%计算(每年14.4%)。付某某以其名下362号房屋作抵押,并办理了抵押登记。付某、赵某自愿为乙方的借款提供连带责任保证担保。当日,王某某通过案外人张某某向赵某账户支付2600000元,赵某出具收条予以确认。

362号房屋档案显示,该房屋系由付某某的母亲赵某与常某某(付某某奶奶)通过买卖的方式过户至付某某名下,房屋成交价为1万元。《主债权及不动产抵押合同》由抵押权人王某某、抵押人付某某及其代理人赵某签字,该合同后附一份《抵押被监护人财产承诺书》,载明“362房产,产权人付某某,现未成年,现做此房产不动产抵押业务,本人作为其监护人,承诺此处房屋抵押贷款,只限于改善住房环境,不挪作他用。声明人:赵某”。

后付某某、付某、赵某未按期偿还借款。王某某诉至法院,认可收到还款104000元,并将其作为本金进行冲抵,请求付某某、赵某、付某向其归还借款本金2496000元及利息,并就付某某名下的362号房屋行使抵押权。

【案件焦点】

1. 本案借贷合同的成立及效力认定问题;2. 王某某能否就本案所涉房屋行使抵押权。

【法院裁判要旨】

北京市通州区人民法院经审理认为:关于本案借款合同的成立及效力。虽然借款手续上有付某某本人签名捺印,但借款金额巨大,付某某并无相应的借款需求,赵某、付某作为付某某的监护人无权代理付某某实施此种不利民事法律行为,二人以共借人、连带保证人的身份在借款手续中签字,不能当然视为对付某某作为借款人的同意或者追认。案涉借款合同对付某某不发生法律效力。根据双方对借款往来经过的陈述及双方提交的证据,案涉借款合同法律关系发生在赵某与王某某之间。

关于王某某能否就本案所涉房屋行使抵押权。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人财产。本案中，付某某名下的房产是由其祖母常某某以明显低于市价的金额转让，应当视为常某某对付某某的赠与，系付某某个人财产。第一，赵某、付某作为监护人，以未成年人名下房产设定抵押不属于纯获利益的行为，借款用途并非为了未成年的利益，系无权代理行为，无效。第二，《房产抵押合同》作为《借款合同》的从合同，不对付某某发生法律效力。第三，王某某作为完全民事行为能力人，理应知晓与未成年人签署借款合同并接受未成年人名下房产提供抵押担保的法律后果，应当尽到比一般出借人更加严格的审核和注意义务。但事实上，王某某系通过借款中介与付某某一家人相识，并无其他接触，也不了解其家庭情况，难以认定王某某尽到了相应审核义务。

北京市通州区人民法院于2023年11月16日作出(2023)京0112民初10249号民事判决：

一、被告赵某偿还原告王某某借款本金2496000元及利息(以2496000元未给付款项为基数，自2022年9月3日起计算至实际给付之日止，按照年利率14.4%计算)；

二、被告付某就本判决主文第一项确定的债务向原告王某某承担连带保证责任；

三、驳回原告王某某的其他诉讼请求。

一审判决后，王某某提起上诉。

北京市第三中级人民法院同意一审法院裁判意见，于2024年4月22日作出(2024)京03民终1749号民事判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

如今，未成年人通过赠与、继承等方式取得个人财产的情况越来越多。父母作为未成年人的监护人，对未成年人名下财产进行代管。而现实中，父母出于各种原因以未成年人个人财产设定抵押的现象层出不穷。《中华人民共和国

民法典》第三十五条第一款规定：“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。”该条规定了父母处分未成年人财产的基本原则，但是较为笼统，对于如何认定父母以未成年人个人财产设定抵押的行为效力问题缺乏明确的裁判指引。在司法实践中，该问题往往成为争议焦点，本案亦是如此。对此问题，本案的主要审理思路如下。

首先，关于父母以未成年人个人财产设定抵押行为的性质。一方面，从付某某的角度分析，根据民法典规定，八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。本案中，虽然付某某在借款合同、抵押合同上签字，但是付某某本身并没有借款需求，将其名下财产进行抵押借款并非纯获利益或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为，故付某某不得独立行使此种行为，需要由其法定代理人代理或者同意、追认。同意、追认通常适用于限制民事行为能力人独立实施民事法律行为导致行为效力待定的情形，而本案中付某某与其父母同时在借款抵押材料上签字，因此不能将此视为付某、赵某对付某某借款抵押行为的同意、追认，而只能视为代理。另一方面，从付某、赵某的角度分析，父母虽然系未成年人的监护人和法定代表人，但是未成年子女有其独立人格和独立财产权，对于未成年人的个人财产，父母并不享有所有权，父母以未成年人个人财产设定抵押，系基于其法定代理人身份对未成年人个人财产进行处分，因此该行为性质应当认定为代理，而非法律上的处分。

其次，需要判断该代理行为系有权代理或无权代理。《中华人民共和国民法典》第三十五条第一款对监护权的行使作出了限制，即监护人只能在为被监护人利益的情况下行使监护权，不享有非为被监护人利益的监护权。从这个意义上来看，监护人行使监护权时，只有在“为被监护人利益”的情况下才是有权代理，否则应认定为无权代理。“为被监护人利益”这一表述较为抽象，也没有明确界定的标准，因此需要法院在个案中根据实际情况予以判断。为

未成年人的个人财产设定抵押本身就是一个高风险性的行为，因此应当对“为被监护人利益”进行较为限缩的解释。通常认为，若抵押所担保的借款系直接用于未成年人的生活、学习、教育或医疗等方面，则可以认定为“为被监护人利益”。本案中，借款合同上载明的借款用途为“家庭支出”，且不论此种通过家庭利益间接有利于未成年人的情形是否能认定为“为维护被监护人利益”，实际上，根据本案查明的事实，涉案借款实际上是由赵某转借给了其弟弟使用。因此，从实际结果上来看，涉案借款并非有利于付某某利益，难以将该抵押行为认定为“为被监护人利益”，因此该抵押行为的性质应为无权代理。

最后，在定性为无权代理的基础上，认定抵押行为的效力。通常来讲，无权代理行为效力待定，在构成表见代理的情况下，行为有效。

第一，关于该抵押行为是否构成表见代理。与普通代理不同，父母作为法定代理人代理未成年人作出民事法律行为的权限已经由法律明确规定，即“为被监护人利益”，因此应当视为公众对该权限均已知悉，相对人善意的范围仅限于其已经就抵押借款用途是否“为被监护人利益”尽到合理审查义务的情形。在上述前提下，相对人作为完全民事行为能力人，理应知晓与未成年人签署借款合同并接受未成年人个人财产提供抵押担保的法律后果，在出借和接受抵押时应当尽到比一般情形更加严格的审核和注意义务，如合理审查未成年人名下财产的来源、借款的真正用途等。在本案中，王某某与付某某一家人系通过借款中介相识，在此前并未有过接触，王某某也并不了解其家庭情况，并未对借款真实用途进行审核，因此无法认定其为善意，不能构成表见代理。

第二，若不构成表见代理，则为狭义无权代理，效力待定，需由权利人追认或拒绝。然而，未成年人在成为完全民事行为能力人之前无法做出相应意思表示，其父母作为该抵押行为的无权代理人也无权代未成年人做出相应意思表示，这就导致该法律行为可能长期处于效力待定的法律效力，这不利于维护市场秩序的稳定，也会使未成年人财产权益长期处于不确定状态。因此，就需要法院对该行为的效力进行确认，此时就涉及对未成年人利益与交易安全、相对

人利益的价值衡量问题。在我国法律中，多处体现出对未成年人的特别保护，原因在于未成年人意思能力不健全，属于弱势群体，在从事法律行为、参与民事法律关系时难以有效维护自身利益，容易受到损害。儿童是祖国的未来、民族的希望，其健康成长关乎国家前途，保护未成年人利益是家庭、社会、国家的共同责任。因此，在价值衡量上，应优先保护未成年人利益，而非倾向于交易安全的维护，以实现未成年人利益的最大化保障。在此种价值选择之下，应当认定父母以未成年人个人财产设定抵押的行为无效。

编写人：北京市通州区人民法院 秦运瑞 赵菁菁

无权处分情形下典当行未尽审查义务不能善意取得抵押权

——某典当行诉于某某典当案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市丰台区人民法院(2023)京0106民初14845号民事判决书

2. 案由：典当纠纷

3. 当事人

原告：某典当行

被告：于某某

第三人：齐某某

【基本案情】

2022年10月14日，于某某与某甲典当行(以下简称某典当行)签订《房 地产抵押典当合同》，约定将其所有的坐落于某小区×号楼×层304号(以下简

称304号房屋)典当给某典当行获取当金,并约定,于某某应向某典当行提供 房屋买卖合同书原件、房屋产权证原件及/或能够证明其对该房屋享有完全处置 权的证明文件等。当金为1700000元,为房产评估价格的50%,抵押典当期限 自2022年10月14日至2023年4月13日,典当综合费用为每月2.5%,未按 期归还当金、支付利息、典当综合费用的每日按照当金数额0.5%支付违约金和相关费用,同时约定了续当、赎当、绝当、抵押房产处分等相关条款,同时 约定绝当后应当按照合同约定的标准继续支付典当综合费用和利息。同日,于 某某与某典当行(乙方、抵押权人)签订《主债权及不动产最高额抵押合同(不动产登记专用)》,就304号房屋办理抵押登记,并取得不动产登记证明。 某典当行出具相应当票,典当期限为一个月,按期支付利息出具续当票,于某某已支付三期利息并出具相应续当票。后因于某某未按约定还款,某典当行诉 至法院。

另查,304号房屋为于某某、齐某某夫妻以房屋拆迁所得款共同购买的, 产权登记在于某某一人名下,登记原因为绿隔项目房屋,2021年1月13日, 于某某取得房屋所有权,共有情况为单独所有,登记类型为补换证登记,登记 原因为补证。于某某、齐某某夫妻与家人一直居住至今。

某典当行称其与于某某的典当合同签订、不动产抵押等工作过程中均严格 按照规范要求 and 业务流程进行办理,于某某办理典当时提交了身份证、房产证, 且房产证原件仍在某典当行处保管,履行了查验证件、实地勘察家访评估、签 订合同、办理抵押登记、签署当票、放款、客户服务及续当等全部义务,办理 业务时不

知道房屋的共有情况，于某某完全没说过，亦不知晓婚姻情况，其已 经善意取得房产抵押权。

【案件焦点】

1. 齐某某是否为案涉房屋共有人，于某某擅自抵押案涉房屋是否构成无权 处分；2. 无权处分情形下，案涉房产典当抵押合同的效力如何认定；3. 因无权 处分对已办理抵押登记的房产产生争议，某典当行是否对案涉房屋的抵押权构 成善意取得；4. 某典当行是否能够预先扣除一个月综合管理费用，典期内息费

的收取标准以及绝当后利息、罚息、综合管理费、违约金和其他费用的计算标准如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：

1. 齐某某是否为案涉房屋共有人。本案中，304号房屋虽登记在于某某一人名下，但购置于其与齐某某婚姻关系存续期间，应属于夫妻共同财产，于某某和齐某某共同对304号房屋享有所有权。

2. 案涉房产典当抵押合同、主债权及不动产最高额抵押合同是否有效。合同订立的当事人对于标的物是否具有所有权，并不影响合同的效力。于某某与某典当行签订的案涉房产典当抵押合同、主债权及不动产最高额抵押合同均系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性、禁止性规定，亦无证据证明存在恶意串通情形，故应认定为合法有效。现于某某未依约偿还本息，应承担违约责任，合同约定的综合费用利率标准并无不当。故，某典当行要求于某某返还借款本金、支付利息127500元的诉讼请求，法院予以支持。

3. 某典当行是否对案涉房屋享有抵押权。当事人以所有权、使用权不明或者者有争议的财产抵押，经审查构成无权处分的，人民法院应当依照《中华人民共和国民法典》第三百一十一条的规定处理。当事人善意取得其他物权的，参照适用《中华人民共和国民法典》第三百一十一条前两款规定。本案中，于某某对于304号房屋的抵押行为构成无权处分，某典当行已实际支付于某某当金，并办理相应的抵押登记，其是否构成善意取得的关键在于受让不动产时是否为善意，就本案，判断是否为善意的标准在于某典当行是否已尽到审查义务。

首先，物权登记并非确认物权的唯一依据。法律赋予不动产登记簿是物权归属的根据而非唯一确定的依据，仅作为一种权利推定依据，可能存在着真实权利状态与登记状态不一致的情形。某典当行不应仅仅依据不动产权属证书的记载情况，就认定案涉房屋为于某某单独所有，还应进一步对案涉房屋的权属进行核实。

其次，典当公司应负有严格的审查责任和义务。某典当行自2017年即取得

了房地产抵押典当业务的相关许可，具有丰富的房地产典当经验，亦应具备相应的风险防控意识和审查能力。案涉合同约定的典当综合费用为每月2.5%，明显高于一般的民间借贷利率上限，根据权利义务相对等原则，某典当行理应有更为严格的注意义务和审查责任。根据《典当管理办法》第三十五条、《北京市典当行监督管理办法》第二十九条之规定，且根据合同约定，于某某应向某典当行提供房屋买卖合同书原件、房屋产权证原件、能够证明于某某对该房屋享有完全处置权的证明文件后，才能够将案涉房屋进行抵押典当。经询问，某典当行表示因疫情于某某并未提供其他材料，亦未出具其他书面说明或书面承诺。人户勘察时，某典当行已知晓屋内有其他人员居住，但并未询问同住人员案涉房屋情况。另，办理案涉典当业务时，于某某已年近五十岁，根据常理某典当行应对于某某的婚姻状况进行审查。

综上，某典当行对于案涉房屋的权属未尽到相应审查义务，故不构成善意取得，某典当行对于304号房屋不享有抵押权。

关于违约金，根据合同约定绝当后应按照合同约定继续支付典当综合费用和利息，某典当行认可其主张的标准过高、同意法院酌情调整，故法院根据合同约定及履行情况对违约金标准依法予以调整。

北京市丰台区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百一十六条、第二百一十七条、第二百三十四条、第二百九十九条、第三百零一条、第三百一十一条、第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

- 一、于某某于本判决生效之日起七日内返还某典当行借款本金1700000元；
- 二、于某某于本判决生效之日起七日内支付某典当行利息127500元；

三、于某某于本判决生效之日起七日内支付某典当行违约金(以1700000元为基数，自2023年4月13日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)；

四、于某某于本判决生效之日起七日内支付某典当行律师费100000元；

五、驳回某典当行的其他诉讼请求。

判决作出后，当事人均未上诉，现该判决已经生效。

【法官后语】

典当作为传统的一种融资方式，具有与一般贷款无法比拟的优势，具有方便、快捷特点，是民间短期融资、急需融资的重要途径之一。因无权处分签订房地产抵押典当合同或当物质押合同引发的纠纷日益增多，典当行在设立房产抵押权时应尽到哪种审查义务、综合管理费是否能够预先扣除、当期及绝当后息费标准的认定是典当纠纷常见的争议焦点。本案为解决以上问题裁判提供了具体指引，是较为典型的案例。

一、无权处分情形下，典当行“善意取得抵押权”之“善意”标准的认定

在无权处分情形下，抵押权人是否善意取得抵押权，应当符合《中华人民共和国民法典》第三百一十一条规定抵押权人在取得抵押权是善意的、房产以合理的价格抵押、房产抵押已经办理抵押权登记手续三个条件。其中“善意”的认定，应当对抵押权人在签订房产抵押合同、办理抵押登记过程中是否尽到了一般人应有的“注意义务”为标准。在房产抵押典当合同中，当事人以设立房产抵押权来获取当金，判断某典当行在设立抵押权时是否“善意”，应当站在某典当行的角度对其在典当合同中应有的“注意义务”和“审查责任”为判断标准。某典当行作为依法取得相关典当业务许可的金融机构，具有专业的典当经验和风险防控意识，其“注意义务”应当显著区别于一般人。人民法院在审查某典当行是否尽到了与其典当专业水准相匹配的注意义务和审查义务时，应从某典当行是否对产权登记情况、权属来源材料、占有使用情况、当户婚姻情况等尽职调查和审查的综合情况来判断设立抵押时是否为“善意”。

本案中，某典当行仅对当户的身份证、权利证书原件进行审查，未积极向房屋登记管理部门查询登记信息及档案材料，也未强制要求当户提供具有完全处分权的证明材料或房屋来源材料；在入户调查勘验过程中虽发现有同住人员，但未向同住人员核实当户同其他同住人员的关系和房屋产权情况；在当户已经

年过50岁的情况下，未主动询问及核实当户的婚姻状况，仅以抵押人未作意思表示即默认其婚姻状况，未及时察觉可能存在无权处分的情形。因此，某典当行存在疏忽大意乃至放任的故意，未尽到与其专业能力、与其收取高息的权利不相匹配的注意义务和审查义务，大大加大无权处分致使抵押权未设立的风险，即使房产办理了抵押登记手续，也不能善意取得房产的抵押权。

二、典当纠纷中典当综合费用是否可以预扣的认定

首先，应当明确利息和综合费用的区别。从法律规定上看，《典当管理办法》第三十七条规定，典当当金利率，按中国人民银行公布的银行机构六个月期法定贷款利率及典当期限折算后执行。《典当管理办法》第三十八条规定，典当综合费用包括各种服务及管理费用。房地产抵押典当的月综合费率不得超过当金的27%^①。《典当管理办法》对二者均进行了规定，但叠加高于民间借贷利率的最高上限。从典当综合费用与利息的性质来看，利息属于资金占用期间的孳息，属于直接发生的损失范畴，而典当综合费用是对当物进行保管、办理保险等事务发生的费用，属于间接发生的损失范畴。由此，典当利息和典当综合费用应属于不同的范畴，均有相应的规定对其进行限制，综合费用为典当行经营业务所付出的服务、管理、劳务等的对价，与本金占有、使用、收益等权益无关，综合典当费用不适用于利息不得预先扣除的规定。

应当认为，综合典当费用的一次性扣除，侵害了当户使用当金的期限利益，造成典当行与当户的利益失衡。但收取综合费用作为典当行的一种惯例有其特殊性，在不影响当金使用的期限利益的情况下应当允许，故可认可典当行预先扣除当金发放第一个月的综合管理费用较为合适。

本案中，双方当事人开具当票、支付当金和支付首月典当综合费用均在同一天进行，当户认可当天收到全额当金，且当事人对综合费用预先扣除没有进行抗辩，因此预先扣除综合典当费用合法有效，法院认定的当金金额为170万元。

三、司法实践中对于当期内及绝当后息费标准的界定

对于典当期内的息费认定。典当行具有金融机构的地位，收取资金使用价

